



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Palo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **34775/2018** promossa da:

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. RIPABELLI PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 5 86100 CAMPOBASSO

ATTORE/OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F. P.IVA_2), con il patrocinio dell'avv. PILLOSIO VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA CADORNA, 18 22100 COMO presso il difensore avv. PILLOSIO VALENTINA

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

Per l'attrice/opponente:

Si precisano le conclusioni così come rassegnate nell'atto di citazione in opposizione e reiterate nella memoria istruttoria 1° termine e che vengono di seguito riprodotte:

"- In via preliminare: Accogliere l'eccezione di incompetenza territoriale formulata con il presente atto e, per l'effetto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore di quello di Campobasso, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque completamente inefficace l'opposto decreto ingiuntivo n. 10100/2018 del 30/04/2018 emesso nel giudizio nrg. 18078/2018 dal Tribunale di Milano. Rigettare integralmente ogni eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto inammissibile e carente di tutti i requisiti richiesti dalla legge per le ragioni sopra dettagliatamente esposte;

- Nel merito: Accogliere la proposta opposizione e per l'effetto, accertata e dichiarata anche e laddove ritenuto, la inesistenza, nullità, annullabilità, inefficacia del contratto di fornitura dell'energia elettrica, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e comunque completamente inefficace e/o inammissibile e/o improcedibile l'opposto decreto ingiuntivo n. 10100/2018 del 30/04/2018 emesso nel giudizio nrg. 18078/2018 dal Tribunale di Milano, per tutte le ragioni sopra dettagliatamente esposte; Accertare e dichiarare, ad ogni buon conto, l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_2, sia con riferimento all'an che al quantum ed

al quomodo dichiarando che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;

- In via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_2, sia con riferimento all'an che al quantum che al quomodo, dichiarando, ad ogni buon conto, che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta in ordine agli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 per le ragioni sopra esposte, con conseguente riduzione della pretesa creditoria, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.

- Ancora via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_2, sia con riferimento all'an che al quantum che al quomodo, dichiarando, ad ogni buon conto, che nulla è dovuto dalla parte opponente alla parte opposta in ordine alla nota di credito del 31/12/2017 dell'importo di € 193.010,40, con conseguente riduzione della pretesa creditoria, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto.

- Sempre in via subordinata ed in ogni caso, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza della pretesa creditoria così come azionata dalla Controparte_1, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti Controparte_2, sia con riferimento all'an che al quantum che al quomodo, dichiarando, ad ogni buon conto, che nulla è dovuto dalla parte.

Per la convenuta/opposta:

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, previa concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto:

IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:

- **confermare** la propria competenza territoriale;

- **rigettare** tutte le avverse domande ed eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa;

- **respingere** l'opposizione, così come proposta dal Controparte_2 [...] , poiché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in narrativa e, per l'effetto, **confermare** l'opposto decreto ingiuntivo n. 10100/2018, n. 18078/2018 R.G. emesso dal Tribunale di Milano, con ogni conseguente statuizione sulle risultanze di causa;

- **accertare** il diritto di credito della deducente e, per l'effetto, **condannare** l'attrice opponente al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 217.343,37=, oltre interessi moratori da calcolarsi fino all'effettivo saldo, ovvero di quella ritenuta equa dal Giudicante adito, in corso di causa.

IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrenze, come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2

[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 10100/2018 (RG 18078/2018), con il quale il Tribunale di Milano gli ha ingiunto di pagare in favore di Controparte_1 la somma di € 217.343,37 oltre interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 e spese della procedura, a titolo di fornitura di energia elettrica.

A sostegno dell'opposizione il CP_2 ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del

Tribunale adito in via monitoria in favore del Tribunale di Campobasso:

ai sensi degli artt. 18, 19 e 20 cpc nella cui circoscrizione ricade il **Controparte_3**, dove il **CP_2** ha la propria sede legale, quale forum contractus e forum destinatae solutionis, risultando del tutto sconosciute all'opponente le condizioni generali di contratto da cui, secondo **CP_1** dovrebbe individuarsi la competenza esclusiva del Tribunale di Milano;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 cpc e 1182, comma 3 c.c., “atteso che le somme richieste, essendo ipoteticamente collegate a dei consumi di energia elettrica (tra l'altro contestati), non possono considerarsi liquide né di facile determinazione”;

in applicazione del foro della c.d. tesoreria dell'ente, essendo il **Controparte_2**

[...] un ente pubblico.

Nel merito, in via principale, ha dedotto l'insussistenza della pretesa avversaria stante la mancanza di prova e la carenza di certezza del credito azionato, l'insufficienza delle fatture quale prova del credito vantato, l'erronea ed illegittima determinazione dei consumi, l'illegittimità del quantum, avendo **CP_1** calcolato le maggiorazioni a titolo di IVA non già sull'imponibile dei soli consumi ma su un importo già maggiorato delle imposte, in particolare delle accise sull'energia elettrica e voci di costo incomprensibili.

In via subordinata ha eccepito:

l'erronea applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 stante l'assenza di un valido contratto idoneo a giustificare tale pretesa, evidenziando che, in ogni caso, detti interessi non potrebbero essere applicati né alle accise costituite dall'imposta nazionale erariale di consumo, né, tantomeno, ai costi dei servizi di rete dovuti a **Pt_3**, o su voci incomprensibili come quella di “energia reattiva”, in quanto, diversamente, “si legittimerebbe un chiaro indebito arricchimento a favore della opposta che non ha fornito prova del già avvenuto pagamento di siffatti interessi a favore di **Org_** ed **Pt_3**”;

l'esclusione degli interessi moratori dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72”;

l'inesistenza del credito avendo **CP_1** con missiva del 31.12.2017, comunicato al **CP_2** una nota di credito dell'importo di € 193.010,40;

il divieto di calcolo dell'iva sulle accise e su voci di costo non predeterminate e ignote;

l'erronea applicazione dell'aliquota del 22% nel calcolo iva in quanto “il **[...]**

Controparte_2 espleta anche funzioni dirette all'impiego di energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque”.

Costituendosi in giudizio, parte opposta ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Assegnati i termini di cui all'art. 183, VI comma cpc, senza svolgimento di istruttoria orale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2020, tenuta secondo le modalità della

trattazione scritta e in quella sede trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle difese conclusive. Il relativo provvedimento risulta regolarmente comunicato alle parti il 23.10.2020.

Osserva il Tribunale che l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per le ragioni appresso spiegate. Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).

Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).

In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).

Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115, 1° comma, c.p.c..

Applicando i principi di diritto appena esposti al caso in esame, irrilevante è l'eccezione di parte opponente riguardante la mancanza della prova scritta del credito richiesta ex art. 633 cpc, in quanto la presente fase apre un giudizio a cognizione piena per l'accertamento del diritto di credito vantato dall'attore in senso sostanziale (cioè della convenuta opposta **CP_1**).

Nel merito, a giudizio di questo Tribunale il creditore ha dato la prova del titolo e del rapporto di fornitura esistente con il **CP_2** per i motivi qui di seguito esposti.

In primo luogo, va osservato che il complessivo comportamento dell'opponente, precedente all'instaurazione del giudizio, appare in contrasto con l'istanza di "disconoscimento" del contratto di fornitura fatta con l'opposizione.

Ed invero, l'opponente non ha mai contestato l'erogazione dei servizi di cui al contratto e non ha neppure contestato alcunché a **CP_1** dopo il ricevimento della diffida di pagamento (doc. 20 fasc. opposta).

In secondo luogo, anche il comportamento tenuto in giudizio contraddice l'istanza di "disconoscimento":

da quanto precisato circa l'efficacia estintiva della nota di credito di cui alla missiva prodotta dall'opposta (doc. 23), implica il riconoscimento che il rapporto di debito/credito per cui è lite nasce dal contratto allegato dalla ricorrente in sede monitoria.

Va, inoltre, osservato che il CP_2 in alcun atto difensivo ha mai disconosciuto la firma e il timbro sul contratto, limitando la propria difesa alla non conoscenza delle clausole per non aver ricevuto copia delle condizioni generali di contratto da cui individuarsi la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

Considerato, pertanto, che, in mancanza di specifiche contestazioni, è pacifico che l'opponente ha voluto e conosciuto il documento contrattuale, ne consegue che solo il disconoscimento della firma e del timbro ed eventuale richiesta istruttoria di perizia tecnica grafologica con conseguente accertamento, avrebbe potuto paralizzare la validità e l'applicabilità delle clausole sottoscritte e quindi accettate dal CP_2.

Nessuna difesa in tal senso è stata spiegata dal CP_2, risultando pertanto priva di pregio la questione relativa alla mancata consegna delle condizioni generali di contratto.

Ciò detto con riferimento alla piena validità ed efficacia del contratto tra le odierne parti in causa, deve ora osservarsi l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente.

All'art. 19.2 del predetto contratto le parti hanno infatti individuato, per ogni controversia nascente dal contratto stesso, con clausola doppiamente sottoscritta, il foro convenzionale del Tribunale di Milano.

Il Tribunale di Milano risulta inoltre competente anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis), avendo il creditore sede legale in Milano.

Né alcun rilievo può avere la natura di ente pubblico della debitrice non essendo il c.d. foro della tesoreria inderogabile. Sul punto, infatti, la Giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "costituisce oramai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte degli enti pubblici, le norme di contabilità che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis", eventualmente in deroga all'art. 1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile, sicché la competenza per territorio può ben radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ." (così, da ultimo, Cass., ord., 12.1.2015, n. 270; v. anche Cass., ord., 7.5.2012, n. 6882; Cass., 8.2.2007, n. 2758; Cass., 8.7.2005, n. 14441)" (Cass., civ. sez. III, del 2 dicembre 2016, n. 24640).

Quanto poi al "disconoscimento" delle fatture azionate, è ovvio che non può trattarsi di disconoscimento in senso tecnico ai sensi dell'art. 214 c.p.c., atteso che detti documenti non costituiscono scritture private (apparentemente) provenienti dal soggetto contro il quale sono prodotti.

Ne' può ritenersi che si tratti di contestazione della conformità della copia prodotta all'originale del documento, in assenza di qualsiasi precisazione in tal senso. Si tratta allora, più semplicemente, di mera contestazione circa la rilevanza del documento ai fini decisorii. Tanto premesso, i documenti in parola,

insieme con le fatture del distributore, attestanti il consumo di energia elettrica prelevata dai nove punti di fornitura siti in: C.da Schieti - San Polo Matese (CB); Via Cantoni - Campochiaro (CB); **CP_4** - Campochiaro (CB); **Controparte_5** - Campochiaro (CB); C.da **CP_6** - **CP_7** (CB); [...] **CP_6** - **CP_7** (CB), vanno a corroborare ulteriormente il quadro probatorio a favore dell'opposta.

Quanto alle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente, deve osservarsi quanto segue.

L'opponente, a giustificazione del mancato pagamento delle fatture azionate, ha dedotto: l'erroneità dei consumi fatturati dalla somministrante in quanto non corrispondenti a quelli reali, l'erronea applicazione degli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, l'esclusione degli interessi moratori dal computo della base imponibile IVA ai sensi dell'art. 15 DPR 633/72, l'inesistenza del credito attesa la nota di credito comunicata da **CP_1** al consorzio, il divieto di calcolo dell'iva sulle accise e su voci di costo non predeterminate e ignote, l'erronea applicazione dell'aliquota del 22% nel calcolo iva.

Per quanto attiene alla prima doglianza, relativa alla contestazione dei consumi, osserva il Tribunale che parte opponente al riguardo ha eccepito, in atto di citazione, "le cifre considerevoli" riportate in bolletta deducendo di essere dotata di un proprio sistema di produzione dell'energia elettrica: due diversi impianti fotovoltaici di elevata potenza che consentono un notevole risparmio di energia.

A sostegno di tale circostanza, ha prodotto i contratti di appalto stipulati con la società **Controparte_8** per lavori di efficientamento energetico (docc. 12 -13) e ha prodotto due fatture: una per i lavori relativi all'impianto fotovoltaico sul tetto di accumulo acqua industriale sito sulla strada Provinciale per Campochiaro e l'altra relativa all'impianto fotovoltaico sul tetto dei locali adibiti a uffici del **CP_2** nell'area dell'impianto di depurazione in C.da Quaglioni in San Polo Matese.

Dalla disamina dei documenti in parola (doc. 12 fasc. opponente) risulta che gli impianti fotovoltaici sarebbero stati realizzati sui tetti dei serbatoi siti sulla strada provinciale per Campochiaro, in Campochiaro (CB); sul tetto dei locali tecnici **Org_2** e **Org_3** del **CP_2** nell'area dell'Impianto di depurazione in C.da Quaglioni in San Polo Matese (CB); sul tetto dei locali adibiti ad Uffici del **CP_2** siti nell'area dell'Impianto di depurazione in C.da Quagliaglioni in San Polo Matese (CB).

Risulta inoltre (doc. 13 fasc. opponente) che il **CP_2** avrebbe incaricato la **CP_8** anche della realizzazione di due impianti fotovoltaici per servire gli impianti di sollevamento e di depurazione, di proprietà del **CP_2** nell'agglomerato industriale consortile in agro dei Comuni di Campochiaro (CB) e San Polo Matese (CB).

Ora, è di tutta evidenza che i punti di fornitura identificati nel contratto (C.da Schieti - San Polo Matese (CB); Via Cantoni - Campochiaro (CB); C.da Cantoni - Campochiaro (CB); **Controparte_5** - Campochiaro (CB); C.da **CP_6** - Trivento (CB); **CP_6** - Trivento (CB), non coincidono con quelli indicati nel documento 12.

Quanto al documento 13, premesso che l'attrice non ha depositato alcun documento che dimostri la

realizzazione dei due impianti fotovoltaici per servire gli impianti di sollevamento e di depurazione siti nell'agglomerato industriale consortile in agro dei Comuni di Campochiaro (CB) e San Polo Matese (CB), che il contratto di fornitura si riferisce a nove punti di prelievo e che l'attrice non ha dedotto a quali dei nove punti di fornitura si riferiscono i due impianti fotovoltaici, anche a voler ritenere che tali impianti siano stati effettivamente realizzati e si riferiscano ai nove punti di fornitura indicati nel contratto, l'attrice non ha comunque provato se ed in quale misura detti impianti avrebbero inciso sui consumi fatturati, senza contare, come evidenziato dall'opposta, che detti impianti potrebbero anche essere stati commissionati per far fronte ad un aumento dell'attività del CP_2 .

Peraltro, parte opponente non ha neppure dedotto né la diversa quantità di energia, rispetto a quella fatturata, che, sempre in tesi, l'opponente avrebbe consumato nel periodo di fatturazione, né ancora, il CP_2 ha addotto al processo alcuno specifico elemento fattuale, da cui potersi quantomeno desumere l'asserita erroneità della rilevazione dei consumi effettuata dalla distributrice sulla base del misuratore e riportata nelle fatture azionate in monitoraggio, così da impedire, in radice, qualsivoglia accertamento in ordine alla sussistenza dell'asserita anomalia dei consumi.

Si richiama, in proposito, il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”, di guisa che “di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.” e che, in particolare, grava sull'utente l'onere di “contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte - secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola -, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione)”, gravando successivamente sul gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del contatore (Cfr. Cass. n. 13605/2019).

Il Tribunale osserva che la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le letture del contatore esposte nelle cd “fatture di trasporto” dell'energia, emesse dal Distributore locale a carico del somministrante (definito dall'Autorità “trader”) per gli oneri di distribuzione dell'energia sulla rete siano in linea di massima prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, salvo che l'utente fornisca elementi idonei ad inficiare l'attendibilità delle misure portate dalle fatture di trasporto, ad esempio perché recanti dati tra loro obiettivamente incoerenti, o incoerenti con la potenza della fornitura, o con altri elementi da cui derivi l'obiettivo inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.

Tanto premesso, il Tribunale reputa che le letture del contatore inviate a CP_1 (definito dall'Org_4 : “trader”) dal distributore locale contenenti i consumi rilevati e imputabili al CP_2 siano prova idonea della misura dell'energia effettivamente erogata, in mancanza di elementi da cui si possa ricavare l'obiettivo

inattendibilità dei dati di misura registrati dal Distributore.

In proposito, si osserva che non risulta prodotta alcuna documentazione che dimostri l'esistenza di impianti fotovoltaici sugli stessi POD oggetto della fornitura "in grado di abbattere anche del 30% il costo della stessa".

Alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione secondo cui, "in linea di principio, nel corrispettivo finale su cui applicare l'iva vanno inclusi anche tutti i tributi di ogni genere e, in particolare, quelli che gravano la produzione e la vendita di beni il cui importo - come per le accise - sia posto a carico del destinatario" (Cass. n. 24015 del 03.10.2018), va rigettata la domanda svolta dall'opponente di rideterminazione delle somme dovute, previo ricalcolo dell'iva.

Sollevata per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - non essendo stata fornita in atti la prova di precedenti contestazioni da parte del somministrato - è l'ulteriore doglianza in merito all'applicazione in bolletta dell'IVA in base al regime ordinario del 22%, anziché in base al regime agevolato del 10% applicabile alle somministrazioni di energia elettrica con riferimento alle funzioni svolte dal

CP_2 .

Sul punto, in base alla ragione più liquida, si osserva che l'intestatario delle bollette azionate in sede monitoria è formalmente il Controparte_2 Controparte_2 , in relazione alle utenze in: C.da Schieti - San Polo Matese (CB); Via Cantoni - Campochiaro (CB); CP_4 - Campochiaro (CB); Controparte_5 - Campochiaro (CB); C.da CP_6 - Trivento (CB); [...] CP_6 - Trivento (CB). Certamente è documentale che le bollette riportano anche l'indicazione, oltre che dei POD e del numero cliente, della partita IVA, e che le stesse venivano inviate al CP_2 , ma ciò non è sufficiente a comprovare la conoscenza di CP_1 circa la natura dell'attività effettivamente svolta dal somministrato presso i punti di fornitura a cui veniva erogata l'energia elettrica.

Pertanto, non risulta che sia stata inviata a CP_1 alcuna formale comunicazione in tal senso da parte del CP_2 .

Di conseguenza va rigettata la domanda dell'opponente di ammissione al trattamento agevolato.

L'opponente ritiene che il CMOR non possa trovare applicazione nel caso di specie: "primo perché, come dimostrato con la produzione documentale del 16.10.2019, il precedente gestore ha attivato tutte le procedure giudiziarie (decreto ingiuntivo ecc.) per il recupero del proprio credito. Dunque, rispetto al precedente fornitore, il CP_2 sta saldando in via transattiva tutte le pendenze. Pertanto la pretesa della CP_1 rappresenta una indebita duplicazione di costi ai danni del CP_2 . Una più stringente valutazione di quanto fin qui sottolineato avrebbe dovuto indurre il Giudice ad una diversa valutazione dell'istanza ex art. 648 c.p.c. impedendo, per giustizia sostanziale, una richiesta tanto illegittima quanto infondata. Ciò che, purtroppo, non si è verificato nel caso di specie e che si auspica possa ancora accadere in sede decisionale.

Secondo perché è la stessa controparte ad ammettere nella II memoria istruttoria che: Controparte ritiene di aver rivenuto una falla di sistema laddove deduce che il CMOR si applicherebbe solo per le reti di bassa tensione e che, quindi, la sua fatturazione, nel caso specifico, sarebbe errata”.

Per quanto attiene alla prima doglianza, relativa alla illegittima e infondata richiesta del CMOR, osserva il Tribunale che né dalla produzione documentale del 16.10.2019, costituita da un Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bologna per la somma di € 513.576,66 nei confronti del CP_2 su ricorso di [...] Controparte_9 e da due Decreti Commissariali del CP_2 aventi ad oggetto l'impignorabilità di somme, né dall'atto di precetto e dall'atto di pignoramento presso terzi, da cui risulta che, opposto il decreto, sia stata concessa la provvisoria esecuzione limitatamente all'importo di € 489.243,63, è possibile desumere il pagamento della somma addebitata a titolo di CMOR.

Difettano dunque gli elementi necessari per accertare l'intervenuto pagamento della somma in parola e in tale contesto l'accoglimento della richiesta dell'opponente sarebbe del tutto arbitraria.

Né rileva il fatto che i debiti con il precedente fornitore siano stati contestati e siano “in fase di chiusura transattiva” posto che da un lato la circostanza non risulta provata, dall'altra l'insoluto con il precedente gestore è circostanza pacifica e riconosciuta dalla stessa attrice opponente.

Per quanto attiene alla doglianza relativa all'indistinta ed errata applicazione del CMOR a tutti i POD del CP_2 anche a quelli alimentati ad alta tensione e secondo cui, per tale ragione, non andava applicato il corrispettivo di morosità, osserva il Tribunale che parte opponente si è al riguardo limitata a riferire quanto affermato dall'opposta, ovvero che alcuni POD non erano alimentati a bassa tensione senza mai dare concretezza alle sue generiche allegazioni.

In particolare, nessuna contestazione specifica è stata mossa in merito alla fattura in cui è stato addebitato il corrispettivo CMOR: né in ordine all'entità dell'importo addebitato a tale titolo, né in ordine al fatto che il predetto corrispettivo sarebbe stato addebitato anche per i punti di fornitura alimentati ad alta tensione, mai neppure indicati.

Tanto premesso, tenuto conto che dalla fattura SC11490/2017 del 2.10.2017 di € 24.333,03 (doc. 18 fasc. monitorio) risulta che i punti di prelievo sui quali è stato addebitato il corrispettivo CMOR sono cinque e segnatamente: POD IT001E692455789; POD IT001E69245788; POD IT001E67314385; POD IT001E65826409; POD IT001E6 9245790 e che detti punti di prelievo sono tutti alimentati a bassa tensione, deve ritenersi la fondatezza della domanda di CP_1 con riferimento all'addebito in parola.

Il CP_2 ha inoltre dedotto l'insussistenza della pretesa creditoria sulla scorta della nota di credito emessa da Repower ex art. 26 DPR 633/72, che recita:

1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all' emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad

aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.

2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'[articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ovvero di un piano attestato ai sensi dell'[articolo 67, terzo comma, lettera d\), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942](#), pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.(1)

3 La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.

4. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 1, comma 567, lett. d\) legge 11 dicembre 2016 n. 232](#)).

5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. (1)

6. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 1, comma 567, lett. d\) legge 11 dicembre 2016 n. 232](#)).

7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'[articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100](#), e successive modificazioni, e all'[articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542](#), e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le

stesse modalita' devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.

8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.

9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facolta' di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'[articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.

11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'[art. 1, comma 567, lett. d\) legge 11 dicembre 2016 n. 232](#)).

12. Ai fini del comma 2 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

- a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

Sul punto, precisato che la richiesta di CTU è stata respinta trattandosi di valutazioni rimesse al Tribunale, deve anzitutto osservarsi che la somministrazione è un contratto di durata e che la risoluzione per morosità non estende i suoi effetti al periodo in cui il somministrante ha erogato l'energia e per cui, ex art. 1458 c.c., pretende il pagamento.

Ora, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione della nota di credito in esame - questione che esula dall'oggetto della presente controversia - il Tribunale osserva che la nota di credito emessa da **CP_1** ai soli fini della detrazione dell'IVA ai sensi art. 26 DPR 633/72 non è idonea ad estinguere il credito indicato nelle fatture cui si riferisce.

Del resto, la stessa nota di credito in esame riporta l'espresso avvertimento che la nota è emessa ai soli fini fiscali e non comporta rinuncia al credito.

Per chiarezza si evidenzia che la nota è stata emessa con riguardo a tutte le fatture azionate, esclusa la fattura con addebito del CMOR, esente da Iva.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'eccezione del **CP_2** secondo cui la nota di credito avrebbe estinto la pretesa creditoria va rigettata.

Parimenti prive di pregio sono le doglianze dell'opponente in ordine alla violazione di norme del Codice del Consumo da parte di **CP_1** in quanto tali norme si applicano esclusivamente al "*consumatore*", inteso come "*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*", profilo, come evidenziato dall'opposta, non associabile al **CP_2**.

In base alla ragione più liquida, gli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 sono dovuti in quanto contrattualmente previsti.

All'udienza del 17.10.2019, l'attrice ha verbalizzato la richiesta di chiamata in causa di **Parte_3** e la domanda di concessione di termine per introdurre la "media-conciliazione".

In punto chiamata di terzo, a prescindere dalla valutazione sulla tardività della richiesta, il Tribunale osserva che l'attrice, sia all'udienza del 17.10.19 che nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., ha chiesto l'autorizzazione a convenire in giudizio **Pt_3** "a cui **CP_1** riconduce la stima dei consumi" (cfr. verbale 17.10.2019); "atteso che non era nella conoscenza del **CP_2** il dato secondo cui la determinazione dei consumi fosse delegata a **Parte_3** (cfr. memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.), senza neppure allegare a quale fine intendeva chiamare in causa il terzo.

Quanto, infine, alla richiesta di concessione di termini per la "media-conciliazione", nella misura in cui la richiesta – in assenza di qualsivoglia precisazione in merito – possa interpretarsi come riferita al tentativo di conciliazione obbligatorio in materia di energia e gas, il Tribunale osserva che il tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità solo nelle controversie promosse dall'utente. Sono dunque tra le altre escluse le cause di opposizione a decreto ingiuntivo per recupero crediti del gestore.

In ogni caso, la questione di procedibilità va eccepita dalla controparte o rilevata dal giudice non oltre la prima udienza.

Peraltro, deve osservarsi che l'opponente si è limitata a chiedere la concessione dei termini per la "media conciliazione" senza sollevare alcuna questione di improcedibilità.

Nel carente contesto allegativo e probatorio di cui si è detto l'opponente non può dolersi della mancata ammissione delle istanze di prova orale avanzate, essendosi la genericità delle deduzioni attoree sopra riferite riversata nei capitoli di prova articolati dall'opponente e, comunque, vertenti su circostanze irrilevanti rispetto al thema decidendum, formulati negativamente o da provarsi mediante documenti.

In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta del **CP_2**

affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.

Presupposto per dare prova dei fatti in un giudizio, infatti, è l'esposizione dei medesimi in maniera dettagliata, l'allegazione della norma che si attaglia al caso specifico e, in forza del principio dell'onere della prova *ex art. 2697 c.c.*, la prova dei fatti rilevanti a sostegno di quanto dedotto.

Nella fattispecie, l'opponente non ha allegato gli errori specifici di contabilizzazione dei consumi e non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno di quanto genericamente eccepito.

La complessiva valutazione di tutti gli elementi sopra indicati porta a ritenere che **CP_1** abbia fornito prova della fondatezza del suo credito.

Conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale o tecnica.

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:

conferma integralmente il decreto ingiuntivo;

condanna parte opponente a pagare a favore di parte opposta, a titolo di refusione delle spese di lite, la somma di € 10.730,00 per compensi, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;

Milano 27 gennaio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Elisabetta Palo